



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/146/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר**

1	בריס שמעון , אחר	1	תובעים
2	בריס חיה בינה, אחר	2	
באמצעות ב"כ : עו"ד ולר חוה			
נגד			
1	משולם שטרן, אחר 059655209	1	נתבעים
2	רבקה שטרן, אחר 023691884	2	
3	אמיתי נגאר, אחר 022206320	3	
4	חפציבה נגאר, אחר 024111171	4	
5	אריק טויטו, אחר 069602977	5	
6	יעל טויטו 014454540	6	
באמצעות ב"כ : עו"ד ליפשיץ בן-ציון			

פסק דין

עניינו העיקרי של פסק דין זה הוא השאלה האם הרחבת דירה שביצעו הנתבעים בוצעה כדין והאם הנתבעים משתמשים שלא כדין ברכוש משותף.

1. הצדדים הם בעלי הזכויות הרלוונטיים בדירות בבית המשותף שברחוב אמרי אמת 5 בבית שמש הידוע כגוש 5379 חלקה 17 (להלן – הבית המשותף). לבית המשותף תקנון מוסכם (להלן – התקנון המוסכם).

2. על פי סעיף 4 לתקנון המוסכם, בבית המשותף 3 כניסות, ובכל אחת 8 דירות. דירות הצדדים להליך זה נמצאות בכניסה ג. בנוסף קובע התקנון המוסכם כי כל חלקי הרכוש המשותף שבתחום כל כניסה יהיו צמודים לדירות שבאותה כניסה בלבד, למעט הקרקע.

3. התובעים הם בעלי הזכויות בדירה מספר 24, הנתבעים 1-2 הם בעלי דירה מספר 23, הנתבעים 3-4 הם בעלי דירה מספר 19 והנתבעים 5-6 הם בעלי דירה מספר 17.

טענות הצדדים בקצרה

4. לטענת התובעים, לנתבעים 1-2 שטח גג מוצמד בשטח שאינו עולה על 36 מ"ר. כמו כן, יש להם היתר בניה המאפשר בניה בהיקף של 54.48 מ"ר על גג הבית המשותף. הנתבעים 1-2 בנו תוספת לדירתם על גג הבית המשותף החורגת מההיתר, וכן פיצלו את דירתם ל-2 דירות ובנו מדרגות על שטח הרכוש המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/146/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לטענתם, הנתבעים 1-2 לא קיבלו הסכמה של 100% מבעלי הדירות בבית המשותף לבנות מחוץ לשטח הגג הצמוד לדירתם, כנדרש בתקנון, ועל כן עליהם להרוס כל בניה מחוץ לשטח האמור.

לטענתם, כל הנתבעים בנו ללא היתר בניה ועל כן עליהם להרוס מה שבנו. הנתבעים 1-2 בנו בניגוד להיתר שניתן להם והנתבעים 3-6 בנו ללא היתר כלל.

לטענת התובעים, הנתבעים בפעולותיהם פגעו בזכויותיהם הקנייניות.

עוד לטענת התובעים, הם זכאים לדמי שימוש מהנתבעים לאור השימוש הנעשה על ידם ברכוש המשותף, במיוחד כאשר עלה כי הגג סגור באופן קבוע תוך שהנתבעים עושים בו שימוש בינם לבין עצמם, ויש לחייבם בדמי שימוש בהתאם לחוות דעתו של השמאי מטעם התובעים.

5. לטענת הנתבעים, ההליך בא לעולם שלא בתום לב, מתוך רצון של התובעים לבנות מספר יחידות על גג הבית המשותף, ולהשתלט על רכוש משותף, אשר לצורך כך שלחו מתחזה לניהול מו"מ. התובעים מנסים לנקום בהם על שמנעו מהם להשתלט על רכושם. התובעים הוציאו היתר בניה על פי הסכמה של 50% מהשכנים בלבד, כאשר אחת החתימות הוצאה במרמה, וההיתר מנוגד לתקנון, תוך שהנתבעים חוסמים גישה לגג הבית המשותף.

התובעים באו בנעלי בעל הדירה הקודם ועל כן מנועים מלטעון כנגד הבניה שביצעו הנתבעים.

מה שנבנה אינו מפריע לתובעים, ומדובר בחיסול חשבונות.

בניית הנתבעים 1-2 על הגג נעשתה לטובת כלל בעלי הדירות.

ככל שלא יגיעו להסכמות עם התובעים וככל שהתביעה לא תדחה, יתאימו הנתבעים 1-2 את הבניה להיתר הבניה. הנתבעים האחרים הגישו בקשות להיתרי בניה עם חתימות כל השכנים למעט התובעים, כדי להכשיר בניה שבנו לפני שנים רבות. חלק מהבניה היא ברישיון.

באשר לדמי השימוש, לטענתם הגג משמש את כל הדיירים על כן אין מקום לפסוק דמי שימוש וכן חוות הדעת מטעם התובעים מתייחסת לאלמנטים שאינם ממין העניין, ועל כן יש לפסול אותה על כל רכיביה. למעלה מן הצורך, הסכום אליו היא מתייחסת אמור להתחלק בין כל השכנים.

ההליך

6. כתב התביעה הוגש ביום 25.4.2022. ביום 24.10.2022 התקיים דיון מקדמי בסיומו נקבע התיק להגשת תצהירים ולישיבת הוכחות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/146/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

7. ביום 13.3.2023 התקיימה ישיבת הוכחות. מטעם התובעים העידו השמאי גרון, מר שליזנגר יצחק, אדריכל אבי ביטון, מר טולדנו ניסים, בעל דירה בבית המשותף, והתובע 1. מטעם הנתבעים העידו הנתבע 1, אדריכל ארז ניסן, הנתבע 3, גב' פאדאווער דבורה, גב' יעל טוויטו ומר רוטנברג. לאחר מכן נקבע התיק לסיכומים בכתב ואלו הוגשו.

דיון והכרעה

התנאים להרחבת דירות הנתבעים

8. סעיף 62(א) **לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969** (להלן – **חוק המקרקעין**) קובע כי הצמדת חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית דורש הסכמה של כל בעלי הדירות. סימן 11 לפרק ו' לחוק המקרקעין, עוסק בהרחבת דירה. בכלל זאת, סעיף 72 **לחוק המקרקעין** קובע הוראה המאפשרת הצמדת חלק מהרכוש המשותף אף ללא הסכמת כל בעלי הדירות, אלא בהסכמת הרוב הקבוע בסעיף, כאשר מדובר בהצמדת חלק מהרכוש המשותף לצורך הרחבת דירה.

סעיף 71ד שבסימן 11 האמור בפרק ו' **לחוק המקרקעין** קובע שניתן להתנות על הוראות סימן 11 האמור כדלקמן:
"א) בעלי הדירות בבית משותף רשאים לקבוע, בתקנון מוסכם, כי הוראות סימן זה לא יחולו עליהם.
ב) אין בהוראות סימן זה כדי לגרוע מהוראה מיוחדת הקיימת בתקנון מוסכם בדבר הרחבת דירה או זכויות בניה"

9. בענייננו, התקנון המוסכם קובע הוראות בכל הנוגע להרחבת דירה ולזכויות בניה. סעיף 3 לתקנון המוסכם, שכותרתו "זכויות בניה" קובע בסעיפים קטנים (1) ו-(2), שבעלי דירות שאליהן מוצמדת קרקע או גג, רשאים לבנות בשטחי ההצמדות ללא קבלת הסכמה מבעלי הדירות האחרים, בכפוף לכך שיבנו בהתאם להיתר בניה.

סעיף 3(3) לתקנון המוסכם קובע **שכל יתר הזכויות לבניה נוספת אם קיימות או תהיינה קיימות בעתיד, יהיו שייכות לכל בעלי הדירות ומימושן מותנה בהסכמת כל בעלי הדירות, יתר הדרישות על פי דין וקבלת היתר בניה כדין.**

10. מכיוון שקיימות הוראות בנושא הרחבת דירות בתקנון המוסכם, הוראות התקנון המוסכם הן שחלות בכל הנוגע לנושא זה, והן גוברות על הוראות סימן 11 לפרק ו' לחוק המקרקעין.

11. על פי הפסיקה, מחסור בהסכמות ניתן לתיקון גם בשלב מאוחר יותר [ר' לעניין זה רע"א 527/14 משה כובאני נ' ישראל לוין (נבו 19.2.2014)]. כדי לוודא שאכן קיימת הסכמה של בעלי הדירות להרחבה מבוקשת, ולאור היותה הסכמה לגריעת חלק מהרכוש המשותף והצמדתו לצמיתות לבעל דירה מסוים, עליה להיות מפורשת ולא כללית, והנטל להוכיח את התנאים הנדרשים מוטל על בעל הדירה המרחיב [לעניין הצורך בהסכמה מפורשת לגריעה מהרכוש המשותף ר' לדוגמה רע"א 259/99 פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב, נה (3)



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/146/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

385 (2001) (להלן – **עניין פליצה**). כפי שנקבע עש"א (מחוזי ת"א) 61803-03-15 **דסטגר נ' גלברג** (נבו, 2.12.2015) (להלן – **עניין דסטגר**) לעניין ביצוע הרחבת בניה:

"אין די בהעדר התנגדות ואין די בהסכמה משתמעת, אלא יש צורך בהסכמה מפורשת, בין בכתב ובין בע"פ, ועל המערערים מוטל נטל הראיה להוכיח כי השיגו את ההסכמות הפוזיטיביות הנדרשות מהרוב הקבוע בחוק"

12. באשר להתאמת הרחבת בניה שבוצעה להיתר שניתן, נקבע בפסיקה שההנחה היא שבעלי הדירות שנתנו הסכמתם לבניה, הסכימו לביצוע הבניה על פי היתר בניה כדין [ר' לעניין זה תיק (מפקח פתח תקוה) 245/19 **גריין חיים דוב נ שטרנבוך איטה לאה** (נבו 4.3.2021) בפסקה 23, תיק (מפקח פתח תקוה) 355/21 **הלר רפאל נ' רוט אלימלך** (נבו 30.8.2022) (להלן – **עניין הלר**) בפסקה 40]. בנוסף, וכפי שנכתב על ידי חברי כב' המפקח מאיר פורת **בעניין הלר**, בין בעל הדירה המרחיב לבעלי הדירות שהסכימו להרחבה נוצר למעשה חוזה שחלקו העיקרי הוא שעבודות ההרחבה יושלמו באופן ראוי ותקין (פסקה 56 לפסק הדין). עניין זה עולה בקנה אחד עם הוראות התקנון המוסכם הקובע כאמור שבניית תוספות בניה, בין אם נדרשת לגביה הסכמה של כל בעלי הדירות ובין אם לא, תהיה בהתאם להיתר שניתן כדין.

13. לאור האמור, על פי הוראות התקנון המוסכם:

בכל הנוגע לבניה שביצעו הנתבעים על השטחים המוצמדים לדירותיהם אשר לפי התקנון קיימת להם זכות לבנות בהם, יש לבחון האם הנתבעים הוכיחו שביצעו את הבניה בהתאם להיתר בניה כדין.

בכל הנוגע לבניה של הנתבעים על גבי הרכוש המשותף, וככל שהיא כוללת שימוש בזכויות בניה, יש לבחון האם הנתבעים קיבלו הסכמות של **כל** בעלי הדירות, וככל שכן, האם הבניה בוצעה בהתאם להיתר בניה כדין.

באשר לצורך בהסכמת **כל בעלי הדירות**, הצדדים לא התייחסו לשאלה האם נדרשת הסכמת בעלי כל הדירות בבית המשותף כולו, או הסכמת בעלי הדירות במבנה ג בו נמצאות דירות הצדדים. על פי הפסיקה, גם בבית משותף מורכב מסוג זה, בו קיימת הצמדה של חלקי הרכוש המשותף לכל אחד מהמבנים, עדיין, לצורך הרחבת דירה, על פי סימן ג1 האמור, בחינת היקף ההסכמות הנדרשות נעשה **מכל בעלי הדירות בכל המבנים** [ר' עש"א (מחוזי חיפה) 36004-06-12 פלאוט נ' הוד (נבו, 7.6.2013); ע"א (מחוזי חיפה) 2821/01 וילסקר נ' לויט (נבו, 8.8.2002) (להלן – **עניין וילסקר**) בפסקה 16; תיק (מפקח על רישום מקרקעין חיפה) 768/17 **כהן זמיר אילנה נ' שילובצקי זיוה** (נבו 7.5.2020)]. בענייננו, נראה כי התקנון המוסכם מתייחס גם הוא לצורך בהסכמת כל בעלי הדירות בבית המשותף, אולם מכיוון שהצדדים לא טענו בעניין, איני מוצאת מקום להכריע בכך, שעה שכפי שiorחב בהמשך, הנתבעים לא הוכיחו הסכמות נדרשות אף בנוגע לבעלי הדירות בכניסה ג.

הרחבת דירת הנתבעים 1-2

14. לנתבעים 1-2 ניתן היתר בניה להרחבת דירתם בשנת 2017. על פי התקנון המוסכם, ובהתאם למופיע בנסח הרישום, שטח הגג הצמוד לדירתם הוא 36 מ"ר. בפועל, קיבלו הנתבעים 1-2 היתר בניה לבניה על שטח גדול יותר, ואין מחלוקת שבנו שלא בהתאם להיתר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/146/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הבניה שקיבלו, וכן על חלק משטח הגג שאינו צמוד לדירתם. כחלק מכך, במקום לבנות מדרגות מתוך דירתם לכיוון ההרחבה, בנו מדרגות מתוך חדר המדרגות המשותף לכיוון הגג, ופתחו כניסה לבניה הנוספת על הגג שניתן להגיע אליה דרך חדר המדרגות.

15. הנתבעים 1-2 אינם מכחישים שהבניה שבוצעה על ידם בוצעה שלא בהתאם להיתר הבניה שניתן להם, או לכל הפחות חזרו בהם מטענה כאמור. באשר לבניה על הרכוש המשותף, לטענתם, קיבלו טרם הבניה, ועוד לפני התובעים רכשו את זכויותיהם בדירתם, הסכמות של כל בעלי הדירות, לרבות מי שהיה בעל דירת התובעים במועדים הרלוונטיים, ועל כן התובעים מנועים מלטעון בעניין.

16. בנוסף, לטענתם הבניה שביצעו בחלק מהרכוש המשותף (המדרגות לגג וחלק מהגג שרוצף, קורה בפרגולה ונבנה בו חדר שירותים ומקלחת נפרד מהיחידה) נעשתה לטובת כלל בעלי הדירות.

17. באשר לאי התאמת בניית הנתבעים 1-2 להיתר עולה כי לא מדובר באי התאמה זניחה, אלא בשינויים משמעותיים ובכללם בניית מדרגות לתוספת הבניה מחוץ לדירת הנתבעים 1-2 במקום מתוך דירתם, ושינוי מיקום של חלק מתוספת הבניה עצמה. הדבר עלה גם מחוות דעתו של אדריכל הנתבעים, וכן מחקירתו הנגדית (ר' לדוגמה פרוטוקול הדיון מיום 13.3.2023 עמוד 12 שורות 1-48, עמוד 13 שורות 1-8). בכלל זאת, בניגוד להיתר, שינו הנתבעים 1-2 את פתח הכניסה המקורי לגג, אשר שימש מעבר למערכות של בעלי דירות שהוצבו על הגג, והביאו להעתקת הגישה, לחלק מהגג המשותף, מהאזור שהיה סמוך לתוספת הבניה שלהם, לשטח הגג הצמוד לדירת התובעים (ר' חקירת הנתבע 1 בפרוטוקול הדיון מיום 13.3.2023 עמוד 9 שורות 31-38, עמוד 10 שורות 10-15). בנוסף, בפועל עולה כי תוספת הבניה נבנתה כיחידה חדשה נפרדת, שהכניסה אליה חיצונית ולא מתוך דירת הנתבעים 1-2, זאת בניגוד להיתר הבניה, על פיו הייתה אמורה להיות הרחבה של דירת הנתבעים 1-2 (ר' חקירה נגדית של הנתבע 1 בפרוטוקול הדיון מיום 13.3.2023 עמוד 10 שורות 41-47). הנתבעים 1-2 אף הודו שהיחידה הושכרה בנפרד מהדירה (ר' לדוגמה פרוטוקול הדיון מיום 13.3.2023 עמוד 10 שורות 44-47).

18. עצם הבניה של יחידה נפרדת, להבדיל מהרחבת דירה, דורשת הסכמה של כל בעלי הדירות, גם אלמלא הוראות התקנון (ר' ענין וילסקר בפסקה 15), מה גם שבענייננו, היחידה הנפרדת נבנתה בניגוד להוראות היתר הבניה, שהתיר הרחבת דירה בלבד, אף זאת באופן המנוגד להוראות התקנון הדורש התאמה להיתר הבניה.

19. באשר לבניה שבוצעה על גבי הרכוש המשותף, אין בידי לקבל את טענתם של הנתבעים 1-2 שהמרפסת שבנו על הגג, ובכלל זאת חדר השירותים והמקלחת שבנו על אותה מרפסת נועדו לשמש את כל השכנים. אף שכיום לא קיימת גישה ישירה בין החדר האמור לתוספת הבניה, הרי שאין כל הגיון שבעלי דירות שיש להם חדרי שירותים ומקלחת בתוך דירתם, יעלו באופן שוטף לגג הבית המשותף כדי להשתמש בחדר שירותים ומקלחת. מובן שסמיכות חדר השירותים והמקלחת ליחידה הנפרדת שבנו הנתבעים 1-2 על הגג תוך ריצוף וקירוי בפרגולה של מרפסת הגג שנוצרה בין היחידה לבין חדר השירותים והמקלחת, מביאה למצב שבו על פי ההיגיון, השימוש בחדר האמור נועד לדיירי יחידת המגורים. בעניין זה אני נותנת אמון בעדות התובע, שלא נסתרה, על פיה המפתח לגג הסמוך לדירת הנתבעים לרבות לחדר השירותים והמקלחת האמור נמצא בידי בתם של הנתבעים 1-2 ובעלה,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/146/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המתגוררים בדירת הנתבעים 1-2, וכי במרבית התקופה הגג היה נעול (ר' חקירתו הנגדית של התובע בפרוטוקול הדיון מיום 13.3.2023 עמוד 8 שורות 23-29). ענין זה נתמך גם בעדות שמאי התובעים שנדרש לבקש מבת הנתבעים 1-2 להשאיר את הגג פתוח לצורך ביקורו (פרוטוקול הדיון מיום 13.3.2023 עמוד 2 שורות 1-4). כמו כן מעדות שמאי התובעים עלה שנבנתה פרגולה מטעם הנתבעים 1-2 על אותה מרפסת גג, וכן שהוצב ריהוט על הגג ובכללו כיסא תינוק, אדניות, ערסל, הגג גודר בסורגים וכו', דבר שלא נסתר על ידי הנתבעים (עמוד 2 שורות 49-50, עמוד 3 שורות 30-33). הצבת פרגולה וריהוט כאמור מחזקת את המסקנה שהנתבעים 1-2 או מי מטעמם מבצע שימוש ייחודי בגג.

העובדה שהנתבעים מאפשרים גם לבעלי דירות אחרים, על פי רצונם של הנתבעים 1-2, או על פי סיכום שקיים בינם לבין מי מבעלי הדירות, לעשות שימוש בגג, כפי שעלה מעדויות עדי הנתבעים אינה מהווה ראיה לכך שמדובר בגג הנמצא בשימוש כל בעלי הדירות, אלא לכל היותר שקיימת הסכמה בין הנתבעים 1-2 או מי מטעמם לבין בעלי דירות מסוימים, לענין שימוש מסוים בגג, המתרחש ככל הנראה בתדירות לא גבוהה, כמפורט להלן.

אף שהנתבעת 6 כתבה בתצהירה שהגג משמש את כולם ושהם (הנתבעים 5-6 ילדיהם ונכדיהם) עושים בו שימוש חופשי, הן באזור המרוצף והן בחדר השירותים (סעיפים 11-14 לתצהירה) עלה בחקירתה הנגדית שהיא עצמה עלתה לגג פעם אחת בלבד, משום שהשאילו לה את היחידה על הגג, וכי המקום שימש את השכנים בעיקר בתקופת הקורונה, אם כי טענה שהבנות שלה משתמשות בגג (פרוטוקול הדיון מיום 13.3.2023 עמוד 24 שורות 23-28). מעדותה התרשמתי שלמרות הטענה לשימוש חופשי בגג, השימוש בגג על ידי שכנים שאינם הנתבעים 1-2 או מי מטעמם הוא בהזדמנויות ספציפיות אך לא באופן שוטף, זאת בין היתר לאור קיומו של ריהוט מטעם הנתבעים 1-2 על הגג, והעובדה לא הייתה לנתבעת 6 ידיעה על הזמנים בהם הגג היה נעול כאשר המפתח היה בידי בתם של הנתבעים 1-2 שגרה בדירה, או בידי הנתבעים 3-4 (ר' פרוטוקול הדיון מיום 13.3.2023 עמוד 24 שורות 26-40, 49).

מחקירתו הנגדית של הנתבע 3 (נגאר) על תצהירו, עלה כי השימוש במקלחת והשירותים שעל הגג נעשה בזמן שביצעו שיפוץ בדירתם (עמוד 16 שורות 29-30). כאמור לעיל, גם על פי ההיגיון לא ניתן להניח שמדובר בשימוש תדיר. הנתבע 3 טען בחקירתו שהאמירה בתצהירו "שהגג המרוצף היה פתוח" (סעיף 9 לתצהירו) כוונתה שהיה נעול אך המפתח לגג היה בידי רוטנברג (בתם של הנתבעים 1-2) ובידיו, כנציגי ועד הבית, באופן ששכנים אחרים יכולים לקבלו. למרות זאת לא ידע לומר מי מהשכנים ביקש ממנו את המפתח (עמוד 18 שורות 26-29). אוסיף שאיני מקבלת את הטענה שהחזקת המפתח בידי שני נציגי ועד הבית, שאחד מהם הוא בעל הזכויות ביחידה שעל הגג, יכולה להביא למסקנה שהגג משמש את כל בעלי הדירות, ומהקשר הדברים מובן כי הסיבה המרכזית להחזקת המפתח אצל רוטנברג, בתם של הנתבעים 1-2 היא העובדה שדלת הכניסה לגג היא המעבר היחיד שנבנה על ידם המאפשר להגיע ליחידה שבנו על הגג, ולכל הסובב אותה.

מחקירתה של גבי פאדאווער, בעלת דירה אחרת שנתנה תצהיר מטעם הנתבעים, לענין שימוש חופשי בגג לרבות חדר השירותים והמקלחת (סעיפים 9-14) התרשמתי בניגוד לאמור בתצהירה, שלא מדובר בשימוש שוטף מטעמה, שכן ציינה בחקירתה פעמים ספורות של שימוש, כאשר השימוש במקלחת נעשה פעם אחת בלבד בערב פסח לשטיפת עגלת התאומים, וכן ציינה כי באותו ערב פסח גם השתמשו בטוסטר על הגג, ולא ידעה לומר באלו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/146/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תקופות הגג היה פתוח ובאלו תקופות היה נעול (עמוד 22 שורות 21-2), כאשר גם לטענת הנתבעים, לא היה בידיה מפתח לגג, והיה צורך בקבלת מפתח כדי להגיע אליו (ר' התייחסות לחקירת הנתבע 3 לעיל, וכן חקירתו הנגדית של רוטנברג, חתן הנתבעים 1-2 בעמוד 26 שורות 1-2).

למעשה מי שהצהיר מטעם הנתבעים לעניין שימוש במרפסת הגג שלצד יחידת הנתבעים 1-2 כרכוש משותף, הם הנתבעים עצמם, וגב' פאדאווער, כאשר אף אחד מהם לא הצהיר על שימוש תדיר שהוא עצמו עושה בגג האמור, אלא על מקרים בודדים, או על טענות כלליות בדבר שימוש שעושים ילדיהם, כאשר תשובותיהם בחקירה הנגדית ערערו טענות אלו.

זאת, בצירוף האופן בו נעשתה הבניה, על חשבונם של הנתבעים 1-2 או מי מטעמם (בתם וחתנם – ה"ה רוטנברג), הכוללת את יחידת הדיור הנפרדת של הנתבעים 1-2 שהכניסה אליה היא מאותו גג מרוצף ומקורה בפרגולה, וסמוכה לחדר השירותים והמקלחת שהוסיפו, וכן הריהוט שהוצב על ידם במקום באופן קבוע, תוך נעילת הגג במשך תקופות והשארת המפתח בידי רוטנברג ובידי נאגר (לטענתם בשל היותם נציגי ועד הבית) מצביעה על שימוש ייחודי בגג לטובת הנתבעים 1-2, שאינו מאפשר שימוש דומה לבעלי דירות אחרים.

טענת הנתבעים שהבניה על הגג, לרבות הריצוף, פתרה בעיה של נזילות מי גשמים מהגג המשותף אינה רלוונטית לעניין, שכן הדרך לתקן רטיבות כאמור היא באמצעות נציגות הבית המשותף באופן שאינו פוגע בזכויות יתר בעלי הדירות.

20. מעבר לכך שהנתבעים 1-2 מודים שבנו את תוספת הבניה שלא בהתאם להיתר, הנתבעים 1-2 לא הוכיחו שנתנה להם הסכמה מפורשת, בוודאי לא של כל בעלי הדירות בבית המשותף, אך גם לא מיתר בעלי הדירות בכניסה ג, לבניה על הרכוש המשותף, מעבר ל-36 המטרים שצמודים לדירתם. כאמור, על פי הפסיקה, הסכמות כאמור צריכות להיות **מפורשות, לא די בהיעדר התנגדות, והנטל על הנתבעים להוכיח את קיומן** (ר' לדוגמה **עניין פליצ'ה ועניין דסטגר**). מלבד דירת הנתבעים 1-2, קיימות בכניסה ג' 7 דירות נוספות, שתיים מהן של הנתבעים 3-6 אשר הסכימו לבניה. לפיכך, לצורך הוכחת הטענה שכל בעלי הדירות בכניסה ג הסכימו לבניה מעבר ל-36, היה על הנתבעים 1-2 להראות הסכמה מפורשת של בעלי 5 הדירות הנוספות בכניסה.

21. מעדות רוטנברג, חתנם של הנתבעים 1-2, המתגורר בדירה וטיפול בכל הנוגע לבניה הנוספת, עולה כי הנתבעים 1-2 לא קיבלו את הסכמות כל השכנים כנדרש לבניה. בסעיף 8 לתצהירו הוא אינו מפרט מי מהשכנים חתם על הסכמה לביצוע הבניה, תוך שעולה כי לחלק מהשכנים נשלח דואר רשום מהעירייה אך הם לא התנגדו. כל שצירף רוטנברג לתצהירו הוא אישורם של שני בעלי דירות נוספים אשר אישרו את הבניה. אף אם הבעלים הקודמים של דירת התובעים נתנו הסכמתם לבניה כנטען על ידי הנתבעים 1-2, עדיין אין בכך כדי להביא למסקנה שנתנה הסכמה מפורשת של כל בעלי הדירות כנדרש, שכן עדיין חסרים שני בעלי דירות שלא נתנו הסכמתם לבניה. מחקירתו הנגדית של רוטנברג, עלה שאחד מהם, תפילינסקי, אכן לא נתן הסכמתו, כאשר לטענתו נשלח לו מכתב מהעירייה ולכן הסכמתו לא הייתה רלוונטית (עמוד 27 שורות 41-36).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/146/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

22. התובעים הזמינו לעדות בעל דירה נוסף, שסירב לחתום על תצהיר, מר טולדנו ניסים. מר טולדנו מתגורר בצפת, והעיד שלא זכור לו שמי מהנתבעים פנה אליו אי פעם לבקש הסכמה לבניה שביצעו, וממילא לא נתן להם הסכמה (פרוטוקול הדיון מיום 13.3.2023 עמוד 5 שורות 43-45). טולדנו הבהיר כי ככל שמי מבעלי הדירות מעוניין בהסכמתו, יוכל לבחון את האפשרות לתת הסכמה לאחר שיוסבר לו מה מתכוונים לבצע "ברחל בתך הקטנה" (עמוד 6 שורות 29-30).

23. מהאמור עולה שבעת שבועה שבוצעה הבניה על ידי הנתבעים 1-2, ועד היום, מלבד התובעים, קיימים שני בעלי דירות נוספים בכניסה ג שלא נתנו הסכמה מפורשת לבניה, או הסכמה כלשהי.

24. באשר להסכמת מי שהיה בעלים של דירת התובעים בעת שנדרשו ההסכמות, עלה שדירת התובעים הייתה עד לפני כשנתיים בבעלות שלזינגר. לאחר פטירת האם, בעלת הדירה, מכרו היורשים את הדירה לתובעים. בנם של שלזינגר, יצחק שלזינגר, העיד כי אמנם נערכה אליו פניה, בזמן שאמו הייתה בחיים, טרם הבניה שביצעו הנתבעים 1-2, בהצעה שיבנו במשותף, אולם לאחר ששקל בעניין השיב בשלילה. כמו כן הבהיר שאמנם הסכים לבנית הנתבעים 1-2 אך זאת בכפוף לכך שלא תפגע ברכוש המשותף, וכי הבניה שבוצעה בפועל הפגיעה אותו. כן העיד שלא התבקשה כל הסכמה מאמו שהייתה בעלת הדירה (פרוטוקול הדיון מיום 13.3.2023 עמוד 4 שורות 1-9). על אף שהנתבעים 1-2 טענו ששלזינגר הסכימו לבניה ללא הסתייגות, לא עלה בידם להוכיח את הטענה, ועדותו של יצחק שלזינגר בעניין זה לא נסתרה.

מעדות שלזינגר עולה כי אין בהסכמה המסויגת שנתן כדי להוות הסכמה מפורשת כנדרש בפסיקה. ראשית, שלזינגר לא קיבל מידע אודות היקף הבניה שהנתבעים 1-2 מבקשים לבצע, ושנית, ביקש כי הבניה לא תפגע ברכוש המשותף, ובוודאי לא הסכים לכך שהבניה תפגע ביכולת לבצע תוספת דומה לדירה שהייתה בבעלות אמו, ובהמשך נמכרה לתובעים.

מכיוון שנטל ההוכחה בעניין זה על הנתבעים, הרי שהנתבעים לא הוכיחו הסכמה בלתי מסויגת של שלזינגר לבניה שביצעו.

יתר על כן, גם אם שלזינגר היו נותנים הסכמה מפורשת לבניה, הרי שהיו רשאים לחזור בהם, ככל שהנתבעים 1-2 לא שינו מצבם לרעה על בסיס הסכמה זו. מכיוון שבסיס להסכמה כאמור הוא בניה על פי היתר בניה כדן, ועולה כי הנתבעים 1-2 לא בנו בהתאם להיתר שניתן להם, וחרגו ממנו באופן ניכר, הרי שבכל מקרה הבניה שביצעו הנתבעים 1-2 לא התבססה על הסכמה נטענת כאמור.

לאור האמור, טענת הנתבעים שהתובעים נכנסו בנעלי שלזינגר ועל כן מנועים מלהתנגד כיום לבניה, נדחית.

25. מהאמור עולה שהנתבעים לא הוכיחו הסכמה מפורשת של בעלי 3 מהדירות בכניסה ג, ובכל מקרה, אין בהסכמות שכן נתנו להם, כדי לרפא את העובדה שהבניה בוצעה בניגוד להיתר הבניה שניתן להם. בנסיבות אלו, אף אם הנתבעים יפרקו את כל הבניה שביצעו, ויתאימו אותה להיתר שניתן, לא יהיה בכך כדי לרפא את הצורך בקבלת ההסכמות הדרושות של



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/146/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כל בעלי הדירות, באשר לבניה מעבר להרחבת דירתם ב-36 המטרים על הגג הצמודים לדירה שלהם, תוך שהגישה אליהם תהיה מתוך הדירה.

26. גם טענתם של הנתבעים שהבניה כפי שבוצעה על ידם אינה פוגעת בתובעים, נדחתה. האופן בו בנו הנתבעים 1-2 את התוספת על הגג, והשינוי שביצעו למעבר לגג, מייצר מצב שבו המעבר הנח לגג, באמצעות מדרגות, מוביל לגג הסמוך לדירת הנתבעים 1-2, אך לא מאפשר מעבר נח דומה לגג הסמוך לדירת התובעים, המהווה תמונת ראי לדירת הנתבעים 1-2 ויש לה זכויות דומות לבניית תוספת על פי התקנון. במאמר מוסגר אציין כי על פי תשריט הבית המשותף, הפתח לגג, אליו ניתן היה להגיע לטענת הנתבעים 1-2 באמצעות סולם ארוך מתוך חדר המדרגות, לפני שבנו את גרם המדרגות הנוסף, מופיע דווקא מעל גג הדירה של הנתבעים 1-2 (אך לא בשטח הצמוד לדירתם). במסגרת הבניה שביצעו, הוסיפו הנתבעים 1-2 מדרגות על חשבון הרכוש המשותף המובילות לשטח הגג שמעל דירתם, שעליו בנו את התוספת, ואילו לכיוון הגג הנמצא מעל דירת התובעים ניתן להגיע רק באמצעות סולם (קטן יותר מזה שהוביל לגג בעבר) שהתקינו הנתבעים בתוך גומחה שנוצרה בחדר המדרגות בעקבות הבנייה שביצעו, מעליה קיים פתח קטן. מהראיות שהוצגו עולה שמדובר במעבר לא נח, שלכל היותר יכול לשמש בדחק מעבר לאנשי מקצוע, אך בטח לא מעבר חופשי למי שרוצה להשתמש בגג, ובכל מקרה מעבר שאינו תקני (ר' חקירתו של המומחה, הנדסאי אדריכלות, מטעם התובעים בפרוטוקול הדיון מיום 13.3.2023 עמוד 4 שורות 40-45). גם לעניין פתח זה, המוביל לגג שמעל דירת הנתבעים, עלה שהיה נעול, לפחות עד סמוך לשיבת ההוכחות, במפתח שלא נמסר לתובעים (ר' חקירתו הנגדית של התובע 1 בפרוטוקול הדיון מיום 13.3.2023 עמוד 8 שורות 23-31 בהתייחס לשני חלקי הגג).

27. מהאמור עולה שהנתבעים בנו בניגוד להיתר, וכן על גבי רכוש משותף, שעליו לא היו רשאים לבנות ללא הסכמת כל בעלי הדירות, והסכמה כאמור לא נתנה להם. למעשה, כל שרשאים היו הנתבעים 1-2 לבנות, הוא תוספת בגודל של 36 מ"ר על גבי שטח הגג הצמוד לדירתם, כאשר המעבר לאותה תוספת יהיה מתוך דירתם בלבד, וזאת על פי היתר בניה מאושר כדין.

28. באשר לבניה שביצעו הנתבעים 1-2 באמצעות תוספת חדר בקומת דירתם, לגבי לא עלתה מחלוקת לעניין בנייתו בהתאם להיתר, הרי שעניין ההסכמות של בעלי הדירות לבניית תוספת זו לא הועלה בכתב התביעה שהוגש, ולא נתנה לו התייחסות מפורשת גם בהמשך. יכול שהסיבה לכך היא שגם התובעים מעוניינים לבצע תוספת בקומת דירתם, אולם גם לעניין זה לא נתנה התייחסות ברורה לא על ידי התובעים ולא על ידי הנתבעים, וככל שביקשו התובעים סעד כללי בעניין, הרי שזנחו את הדבר בסיכומיהם. בנסיבות אלו, שבהן מתן צו הריסה לחלק מדירה הוא סעד פוגעני, והתובעים לא ביקשו סעד כאמור באופן מפורש, ולא הציבו תשתית עובדתית מתאימה בעניינו, איני מוצאת מקום למתן סעד בעניין זה.

הרחבת דירת הנתבעים 3-4 והנתבע 5

29. אין מחלוקת שהרחבת דירת הנתבעים 3-4 והנתבעים 5-6 בוצעה ללא היתר בניה, ואין מחלוקת שלא בוצעה על שטחים הצמודים לדירותיהם. אולם לטענת הנתבעים, הבניה בוצעה לפני שנים רבות, ואף אחד לא מחה כנגד אותה בניה, אשר הייתה קיימת בזמן שהתובעים נכנסו לדירתם. לפיכך לטענתם התובעים מנועים מלטעון כלפי הבניה האמורה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/146/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בנוסף לטענתם, הנתבעים האמורים הגישו לאחרונה בקשה להיתר בניה לאותה בניה, החתומה על ידי כל השכנים למעט התובעים.

30. על פי תצהיר הנתבע 3 (נגאר) ביצעו תוספת חדר בשנת 1997, עוד לפני רישום התקנון המוסכם, ובהמשך בצעו בניה נוספת בשנת 2008 ללא התנגדות מי מהשכנים (סעיף 5 לתצהיר). מחקירתו הנגדית עלה שביצעו בניה ללא היתר במסגרתה הוסיפו כ-7.35 מ"ר לסלון דירתם עם קירוי פוליפח וכן קירו שטח נוסף (עמוד 19 שורות 10-37). לטענת הנתבעים 3-4 הגישו בקשה להיתר. אציין כי כל שהוגש כראיה מטעם הנתבעים 3-4 בהקשר זה הוא אישור במייל מעיריית ירושלים על כך שנקלטה בקשה להיתר ביום 6.2.2023, ללא אינדיקציה לדברים שהתבקשו במסגרת הבקשה. הדברים תואמים את האמור בחוות דעת השמאי גרון מטעם התובעים, על פיה נסגר שטח מרפסת בשטח של 7.35 מ"ר וצורף לסלון, נבנתה מרפסת פתוחה בשטח של 10 מ"ר, וקורה שטח נוסף של מרפסת בשטח של כ-20 מ"ר. אמנם בסיום חוות דעתו ציין השמאי באופן כללי כי 11.77 מ"ר מתוך השטח הנ"ל נבנה בהיתר, אולם הנתבעים לא חקרו אותו על כך, ולא מובן מחוות הדעת לאיזה שטח הדבר מתייחס. מכיוון שבהתאם לפסיקה, נטל ההוכחה להוכחת התנאים הנדרשים לתוספת כאמור מוטל על הנתבעים, הרי שהנתבעים לא הציגו כל היתר מאושר לתוספות האמורות.

31. על פי תצהיר הנתבעת 6 (טויטו) ביצעו תוספת בניה בדירתם בשנת 1997 עוד לפני רישום התקנון המוסכם, ובסביבות שנת 2008, והשכנים מעולם לא התנגדו לכך, והתובעים הגיעו למצב קיים (סעיף 5 לתצהיר). מחקירתה הנגדית עלה שהבניה הנוספת שבנו היא בשטח של בין 40 ל-80 מ"ר, אולם עלה כי בפועל לא הוציאו היתרים לבניה הנוספת, אם כי לטענתה הגישו בקשות להוצאת היתרים (עמוד 23 שורות 10-19). אציין כי כל שהוגש כראיה מטעם הנתבעים 5-6 בהקשר זה הוא אישור במייל מעיריית ירושלים על כך שנקלטה בקשה להיתר ביום 6.2.2023, ללא אינדיקציה לדברים שהתבקשו במסגרת הבקשה. הדברים תואמים את האמור בחוות דעת השמאי גרון מטעם התובעים, על פיה תוספת הבניה שבוצעה היא הרחבה של סלון הדירה על חשבון מרפסת בשטח של 14.7 מ"ר וכן תוספת שטח עיקרי על חשבון חצר בשטח של 5.5 מ"ר, ובנוסף על כך חדר בשטח של כ-20 מ"ר שנבנה על חשבון שטח החצר (עמוד 6 לחוות הדעת). גם באשר לנתבעים 5-6 אמנם בסיום חוות דעתו ציין השמאי באופן כללי כי 11.77 מ"ר מתוך השטח הנ"ל נבנה בהיתר, אולם הנתבעים לא חקרו אותו על כך, ולא מובן מחוות הדעת לאיזה שטח הדבר מתייחס. מכיוון שבהתאם לפסיקה, נטל ההוכחה להוכחת התנאים הנדרשים לתוספת כאמור מוטל על הנתבעים, הרי שהנתבעים לא הציגו כל היתר מאושר לתוספות האמורות. באשר להסכמות הנדרשות, של כל בעלי הדירות, טענה הנתבעת 6 בחקירתה באופן כללי ש"כולם הסכימו" אולם לא זכרה האם חתמו על הסכמה (עמוד 25 שורות 4-9). בוודאי שאין בכך כדי לענות על דרישה של הסכמות מפורשות של כל בעלי הדירות.

32. מהאמור עולה כי הן בדירת הנתבעים 3-4 והן בדירת הנתבעים 5-6 בוצעו תוספות בניה שעיקרן ללא היתר, בשטח של כ-40 מ"ר בכל אחת מהדירות. כמו כן, הנתבעים האמורים לא הוכיחו שהייתה הסכמה של כל בעלי הדירות לתוספות האמורות, כנדרש בתקנון המוסכם, אלא טענו שלא הועלתה התנגדות במהלך השנים שחלפו מאז בוצעה הבניה, או שטענו באופן כללי להסכמה אולם לא הוכיחו זאת. לאור דרישת הפסיקה כאמור לעיל להסכמות מפורשות, הרי שלא ניתן לראות בהיעדר התנגדות כאמור משום הסכמה מפורשת של השכנים לבניה האמורה, מה גם שלאור העובדה שהבניה נעשתה ללא היתר,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/146/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הרי שגם לא ניתן לאשר בדיעבד היעדר הסכמה כאמור, כאשר עולה שנדרשת הסכמת כל בעלי הדירות, ודי בכך שהתובעים אינם מסכימים לכך.

33. מחקירתו הנגדית של התובע 1 עלה שאינו מסכים לבניה של הנתבעים 3-6 גם בשל ההיבטים האסתטיים וגם בשל התנגדותם לבניה שהוא ביקש לבצע. לטענתו, כאשר רכש את הדירה סבר שכל הדירות בנויות עם היתרים, ולא ידע על התוספות של הנתבעים (עמוד 7 שורות 45-50, עמוד 8 שורות 1-6).

בכתב התביעה הטענות כלפי הנתבעים 3-6 היו בכל הנוגע לבניה שביצעו **ללא היתר בניה** (ר' סעיף 19 לכתב התביעה).

לאור האמור, מכיוון שלא התבקש סעד בנוגע לבניה ביצעו בעבר הנתבעים 3-6 בהיתר, הרי שאין מקום לתת סעד בנוגע לבניה כאמור בשטח של 11.77 מ"ר, אף שאין לו תימוכין בראיות הנתבעים, אולם הוזכר באופן כללי בחוות דעת השמאי מטעם התובעים, ככל שישתבר שבידי הנתבעים היתר שניתן בעבר לבניה כאמור. לפיכך, וככל שיציגו הנתבעים **היתר שניתן בעבר**, טרם הגשת התביעה, בנוגע ל-11.77 מ"ר כאמור מתוך השטחים שהוסיפו לדירתם, אזי יהיו רשאים להתאים את הבניה לתוספת זו בלבד. ככל שאין בידם היתר כאמור, הרי שיהא עליהם לפרק את כל תוספות הבניה שביצעו בהתאם למפורט לעיל.

34. באשר ליתר הבניה, אשר אין מחלוקת שנבנתה ללא היתר בניה ובשטחים לגביהם נדרש על פי התקנון המוסכם אישור של כל בעלי הדירות, לצורך ביצוע תוספות בניה, הרי שלא מתקיימים שני התנאים הנדרשים בתקנון, לא קיומו של היתר כדין ולא קיומן של ההסכמות הנדרשות. אף שהנתבעים טענו שכל יתר בעלי הדירות בכניסה ג' למעט התובעים, הסכימו לבניה האמורה, לא הציגו הסכמות כאמור, וממילא לא הוכיחו שנתנו להם הסכמות כנטען. כאמור, הנתבעים 3-6 אמנם טענו שהגישו לאחרונה בקשות להיתר לאישור התוספות האמורות, אולם כלל לא ברור האם תוספות כאמור ניתנות לאישור, דבר שאף הוא לא הוכח על ידי הנתבעים, ולאור אופי הבניה שבוצעה, שחלקה מחומרים קלים, ספק אם אכן ניתן לאשר תוספות מסוג זה.

35. באשר לטענת הנתבעים 3-6 שהתוספות בוצעו לפני שנים רבות והתובעים הגיעו למצב ידוע וקיים, הרי שבכל הנוגע לתוספות שבוצעו ללא היתר בניה, גם אם ניתן היה לראות בהסכמות השכנים במהלך השנים משום הסכמות שבשתיקה, או לחלופין, לראותם כמושתקים כעת, בחלוף הזמן, מלטעון כנגד הבניה שבוצעה, הרי שאין בכך כדי לרפא את העובדה שהבניה בוצעה ללא היתר, הן בניגוד לחוקי התכנון והן בניגוד לתקנון הדורש זאת. כמו כן, אף אם ניתן היה לראות בשתיקת שלזינגר, הבעלים הקודם של דירת התובעים, כהסכמה לבניה, או לראותו כמושתק מלטעון כלפי תוספת הבניה, הרי שלאור הפסיקה כאמור לעיל, לא ניתן לראות בכך הסכמה לבניה ללא היתר, ועל כן, לא ניתן לראות בכך הסכמה לבניה כפי שבוצעה. גם העובדה שהנתבעים 3-6 הגישו לאחר הגשת התביעה בקשות להיתר לאישור הבניה האמורה, אינה מועילה להם, שכן לבקשת כאמור נדרשת כיום הסכמה של **כל בעלי הדירות**, וללא הסכמת התובעים לא ניתן יהיה לקבל את היקף ההסכמות הנדרש.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/146/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

36. מהאמור לעיל עולה שעל הנתבעים 3-6 לפרק את תוספות הבניה שבנו בדירותיהם ללא היתר וללא ההסכמות הנדרשות בהיקף של כ-40 מ"ר לכל אחת מהדירות (בהתאם לשטחים המפורטים לעיל בפסקאות 30, 31).

תום ליבם של התובעים

37. הפסיקה הכירה במצבים חריגים ביותר בטענה שאין לקבל התנגדות של אחד מבעלי הדירות להרחבת דירה בטענה של חוסר תום לב [ר' עש"א (חיפה) 17181-05-11 **גורי אברהם נ' יאיר פדאל** (נבו 20.9.11)].

38. טענותיהם של הנתבעים באשר לחוסר תום הלב של התובעים מתמקדות בפעולות שבוצעו על ידי התובעים או מי מטעמם, לאחר הבניה שבוצעה על ידי הנתבעים, זאת כדי לקבל הסכמה של הנתבעים לצורך ביצוע תוספות בניה על גג דירת התובעים. לטענת הנתבעים, התנגדו לתוספות משום שהיו נרחבות ביותר, ובשל התנגדותם, הוגשה התביעה הנוכחית לביטול תוספות שביצעו הנתבעים.

39. בענייננו, לא ניתן לראות בהתנהלות התובעים חוסר תום לב באופן הגורע מזכותם להתנגד לתוספות הבניה שביצעו הנתבעים.

40. ראשית, כעולה מהאמור לעיל, הנתבעים לא פעלו לבקש הסכמות של כל בעלי הדירות האחרים לפני שבנו את תוספות הבניה לדירותיהם, כנדרש בתקנון המוסכם, ולא בנו את התוספות לדירותיהם בהתאם להיתר בניה. במצב דברים זה, בעוד התובעים פעלו לקבלת הסכמות טרם ביצעו פעולה כלשהי, הנתבעים הם שביצעו פעולות בניה מבלי לבקש הסכמות כלל לכל הפחות מחלק מבעלי הדירות, ועל כן אין מקום שיבואו בטרניה למי שביקש הסכמות אך אלו לא נתנו לו.

41. שנית, בניגוד לטענת הנתבעים בדבר התוספות הנרחבות ביותר שביקשו התובעים לבצע ובכללם טענה לתוספת של יחידות דיור רבות, עולה כי בפועל הבקשה להיתר הבניה שהוגשה מטעם התובעים, ואשר הנתבעים הגישו התנגדות להיתר זה ולאחר מכן ערר, התייחסה לבניה של קומה אחת על גבי הגג הקיים של דירת התובעים (ר' חוות דעת אדריכל הנתבעים בעמוד 3). כך שלא מדובר בפער משמעותי בין הבניה שביקשו התובעים לבצע בפועל, לה התנגדו הנתבעים, לבין זו שבוצעה על ידי הנתבעים 1-2, שהיו הרוח החיה מאחורי ההתנגדות האמורה. יתר על כן, הנתבעים אף הגישו ערר בעניין בקשה מתוקנת להיתר שהגישו התובעים בהמשך, שהתייחסה לבניה על שטח הגג הצמוד לדירתם בלבד, אשר על פי התקנון מותר לבנות עליו, ואשר מצומצם מהיקף הבניה שביצעו הנתבעים 1-2, ללא היתר, ערר שמשכו בסופו של דבר (ר' לדוגמה תשובת הנתבע 1 בחקירתו הנגדית בעמוד 11 שורות 17-20, ותשובת הנתבעת 6 בעמוד 25 שורות 19-26). אם כך, מה לנתבעים שילינו על כך שהתובעים הגישו תביעה המתייחסת לבניה נרחבת יותר, שנעשתה ללא היתר ובניגוד לתקנון המוסכם.

42. שלישית, הבנייה שביצעו כל הנתבעים, גם אם היתר מאושרת, גורעת הן משטחי הרכוש המשותף והן מזכויות הבניה, אשר שייכות גם לתובעים, דבר הפוגע באופן ישיר בזכויותיהם הקנייניות שיש להן משמעות כלכלית.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/146/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

43. בפסק הדין המנחה שניתן ברע"א 6339/97 **רוקר נ' סלומון**, פ"ד נה (1) 199 (1999) (להלן – ענין רוקר) נקבע מהם השיקולים שיש לשקול טרם מתן סעד המורה לצד לסלק ידו ממקרקעין תוך הריסת הבנוי, ובכללם:

"השיקול הראשון הוא עוצמתה של הזכות הקניינית שנפגעה: האם מדובר בזכות במקרקעין או במיטלטלין והאם מדובר בבעלות או בזכות אחרת, חלשה הימנה. השיקול השני הוא עוצמתה של הפגיעה בזכות, לרבות היקף הפגיעה ומשך הפגיעה. השיקול השלישי – משני בחשיבותו לקודמיו – הוא עוצמת התוצאות של הסרת הפגיעה לגבי הפוגע בזכות. השיקול הרביעי הוא התנהגותם של בעלי-הדין. לענין שיקולים אלה, תיראה, לדוגמה, זכות בעלות במקרקעין כבעלת עוצמה גדולה מזכות שכירות; פגיעה בזכות על-ידי תפיסה של שטח גדול תיראה גדולה מפגיעה על-ידי תפיסת שטח זעיר; פגיעה על-ידי תפיסה דרך קבע, או לזמן ארוך, תיראה גדולה מפגיעה על-ידי תפיסה דרך ארעי. ככל שעוצמת הזכות שנפגעה גדולה יותר, ככל שעוצמת הפגיעה גדולה יותר, יצטמצם וילך שיקול-הדעת של בית-המשפט, עד בלי השאיר לו שריד." (עמודים 243-244 לפסק הדין).

כן נקבע כי:

"שיקול-הדעת של בית-המשפט, שבגדרו רשאי הוא שלא להיעתר לתביעה שמטרתה להגן על זכות בעלות או על זכות אחרת במקרקעין, הוא מוגבל ומצומצם ביותר ויופעל רק במקרים חריגים ונדירים." (עמוד 249 לפסק הדין).

44. בענייננו, בנוגע לשיקול הראשון, בהתייחס לתוספות שביצעו כל הנתבעים, ובמיוחד הנתבעים 1-2, מדובר בפגיעה בזכות במקרקעין, תוך ניצול שטח משמעותי מהרכוש המשותף, וזכויות הבניה השייכות לכל בעלי הדירות, כמו כן כל הנתבעים בנו בניגוד לתקנון, הדורש הן הסכמות של כל בעלי הדירות והן היתר בניה כדין. באשר לנתבעים 1-2 מדובר בשינויים משמעותיים של הרכוש המשותף, לטובת נתבעים אלו, שלא ניתן לבצעם בדירת התובעים, על אף שזכויות שתי הדירות אמורות להיות זהות. באשר לנתבעים 3-6 מדובר בתוספות בניה משמעותיות המשנות את הנראות של הבית המשותף, וככל שהיו מאושרות, היו גורעות מזכויות הבניה השייכות גם לתובעים. בנוגע לשיקול השני, מדובר בפגיעה שככל שהייתה מאושרת, הייתה גורעת לצמיחת חלקים נרחבים מהרכוש המשותף ומזכויות הבניה. באשר לשיקול השלישי, אמנם לנתבעים ייגרמו נזקים משמעותיים בשל הצורך בהריסת חלקים נרחבים בדירותיהם, אולם מדובר בחלקים שנבנו מלכתחילה ללא היתר בניה וללא ההסכמות הנדרשות, ועל כן אין לנתבעים להלין אלא על עצמם משום שהתעלמו מהוראות הדין והתקנון בעת שביצעו את תוספות הבניה. באשר לשיקול הרביעי, הרי שכאמור לעיל לא מצאתי חוסר תום לב בהתנהלות התובעים בשל הגשת התביעה, שעה שעולה שהנתבעים הם שבנו ללא הסכמות נדרשות וללא היתר בניה, ולאחר מכן התנגדו לבקשה להיתר שהגישו התובעים, גם כאשר הבקשה הוגשה לגבי תוספות מופחתות מאלו שביצעו הנתבעים עצמם ללא היתר בניה, ואף שהוגשה בנוגע לשטח מוצמד, לגביו כלל לא נדרשה הסכמתם על פי התקנון.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/146/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

45. לאור כל האמור, המסקנה היא שעל הנתבעים לפרק את תוספות הבניה שביצעו בדירותיהם כדלקמן:

על הנתבעים 1-2 לפרק את הגישה שיצרו לגג הנמצא מעל דירתם מחדר המדרגות, ולהשיב את המצב לקדמותו באופן שהגישה לגג תהיה באמצעות סולם לפתח בגג, כפי שהיה טרם העבודות שבוצעו מטעמם. בנוסף עליהם לפרק את כל הבניה שביצעו בעל גג דירתם, באופן שכל שניתן להותיר על הגג האמור הוא הרחבה של הדירה שהגישה אליה הוא מגרם מדרגות מתוך הדירה, על גבי הגג הצמוד לדירתם בלבד (בשטח של 36 מ"ר) ובהתאם להיתר בניה בתוקף. באשר לריצוף הגג, בחלק המהווה רכוש משותף, איני מוצאת מניעה להותיר את הריצוף האמור, ככל שאכן לא ישמש כמעבר או כמרפסת לתוספת הבניה של הנתבעים 1-2, כך שיהווה רכוש משותף ללא סימנים המייחדים אותו לטובת הנתבעים 1-2. על הנתבעים 1-2 לבצע האמור בתוך 4 חודשים מתום תקופת החירום.

46. על הנתבעים 3-4 לפרק בדירתם את סגירת שטח המרפסת בשטח של 7.35 מ"ר שצורף לסלון, וכן את המרפסת פתוחה בשטח של 10 מ"ר, ואת קירוי השטח הנוסף של מרפסת בשטח של כ-20 מ"ר, למעט השטח של 11.77 מ"ר ככל שאכן יש בידם היתר בניה תקף מתקופה שקדמה להגשת התביעה לגבי שטח כאמור.

על הנתבעים 5-6 לפרק בדירתם את ההרחבה של הסלון על חשבון מרפסת בשטח של 14.7 מ"ר, וכן את תוספת שטח עיקרי על חשבון חצר בשטח של 5.5 מ"ר, וכן את החדר הנוסף בשטח של כ-20 מ"ר שבנו על חשבון שטח החצר למעט שטח של 11.77 מ"ר ככל שאכן יש בידם היתר בניה תקף מתקופה שקדמה להגשת התביעה לגבי שטח כאמור.

על הנתבעים 3-6 לבצע האמור בתוך 4 חודשים מתום תקופת החירום.

דמי שימוש ראויים

47. התובעים ביקשו לחייב את הנתבעים 1-2 בדמי שימוש ראויים בסך של 16,900 ₪ בגין השימוש בשטחים הבנויים בגג, מעבר לשטח המוצמד לדירתם. על פי כתב התביעה, מדובר בשימוש על פני תקופה של 52 חודשים. אולם לא ניתן להבין כיצד נעשה החישוב. ראשית, התובעים לא ציינו בכתב התביעה מתי רכשו את דירתם, אולם מנסח הרישום שצורף לכתב התביעה, עולה שההסכם עליו חתמו לרכישת הדירה נחתם רק כ-6 חודשים לפני הגשת התביעה. שנית, לא מובן כיצד הגיעו לסכום האמור. אם מחלקים את הסך של 16,900 ₪ ל-52 חודשים מתקבל סכום של 325 ₪ לחודש. בחוות הדעת השמאית שצורפה מטעם התובעים, צוין סכום של 694 ₪ לחודש (עמוד 23 לחוות הדעת), אולם יש לחלק סכום זה ל-8 הדירות שבכניסה ג. מכאן שהסכום החודשי הוא לכל היותר 87 ₪ (כפי שאף אישר שמאי התובעים בחקירתו הנגדית בפרוטוקול הדיון מיום 13.3.2023 עמוד 2 שורות 44-47). גם לגבי סכום זה, עלה שחקירתו הנגדית של השמאי שיש להפחית ממנו בשל העובדה שהשמאי חישוב את השימוש בחלק מהשטח המשמש גג מרוצף כג שהוא בבעלות הנתבעים, בעוד שבפועל הוא לכל היותר בשימושם הייחודי (עמוד 2 שורות 34-36).

48. על פי הפסיקה, ככלל, יש לחשב את דמי השימוש רק מהתאריך שבו המתנגד לשימוש הביע מחאה מפורשת על שימוש כאמור, כאשר היעדר התנגדות יכולה להתפרש כהסכמה מכללא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/146/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לשימוש [ר' לדוגמה ע"א (מח'-מרכז) 50271-03-17 מועצה מקומית מזכרת בתיה נ' דויטש ואח', (נבו 20.02.18); ת"א (שלום פ"ת) 12577-10-18 מדינת ישראל - רשות מקרקעי ישראל נ' עותמאן ריאן (נבו 11.10.2021)].

49. התובעים לא טענו שמלכתחילה לא הייתה הסכמה מצדם לשימוש שבוצע בגג על ידי הנתבעים 1-2, ולא הבהירו מתי דרשו מהנתבעים 1-2 להפסיק את השימוש האמור. מנסיבות העניין עולה שבתחילה לא התנגדו לשימוש זה. אין מחלוקת שהתובעים הגישו בקשה להיתר בניה על כל שטח הגג שמעל דירתם, תוך שסברו שיקבלו אישור לכך בין היתר לאור הבניה שביצעו הנתבעים 1-2 (ר' לדוגמה חקירתו הנגדית של התובע 1 בפרוטוקול הדיון מיום 13.3.2023 עמוד 8 שורות 3-6), וכן שניהלו מו"מ על הנתבעים 1-2 לעניין בניה על גג דירת התובעים. בנסיבות העניין עולה כי התנגדותם לשימוש של הנתבעים 1-2 בגג נולדה כתוצאה מהערר שהגישו הנתבעים 1-2 על ההיתר שניתן לתובעים, ומההבנה שלא יוכלו לבצע שימוש בחלק מהגג שמעל דירתם. אירועים אלו אירעו בסמוך להגשת התביעה.

בנסיבות אלו בהן לא הוצבה תשתית עובדתית מתאימה לא לתקופת החיוב הנדרש ולא לסכום הנטען, כאשר לכל היותר מדובר בתקופה קצרה ובסכום זניח, איני מוצאת מקום לחייב את הנתבעים 1-2 בדמי שימוש בגין התקופה הרלוונטית לתביעה.

סיום

50. לאור כל האמור לעיל, על הנתבעים 1-2 לפרק את הבניה שביצעו ברכוש המשותף וברכוש הפרטי שלהם בהתאם לאמור לעיל. על הנתבעים 3-6 לפרק את התוספות שביצעו לדירותיהם בהתאם לאמור לעיל.

51. בשל קבלת עיקר סעדי התביעה, על הנתבעים 1-2 לשלם לתובעים הוצאותיהם בסך של 12,000 ₪, על הנתבעים 3-4 לשלם לתובעים הוצאותיהם בסך של 5,000 ₪ ועל הנתבעים 5-6 לשלם לתובעים הוצאותיהם בסך של 5,000 ₪.

ניתן היום, ז' כסלו תשפ"ד, 20 נובמבר 2023, בהיעדר הצדדים

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים